

1502457-43.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... PARISE BRANCO recorda-se do acusado de uma ocorrência de tráfico de drogas. No dia dos fatos, o depoente participava da operação denominada Divisa, que visava ao combate ao tráfico de drogas na região da delegacia. Deslocaram-se até um local já conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Como já haviam feito abordagens no local, já conheciam o modus operandi dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502457-43.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502457-43.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2260940/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 20447431 - 04º D.P. GUARULHOS, 4646/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON CONCEICAO BOTELHO CABRAL JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

WILSON CONCEICAO BOTELHO CABRAL JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Trinta, 1, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 52 porções de maconha, com massa líquida de 195,12 gramas, e 55 porções de cocaína, com massa líquida de 22,25 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e laudo de fls. 13/17) (fls. 71/72). Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/66). Devidamente notificado (fls. 801/81), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 92/93). A denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 2022 (fls. 95/97). Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada

no dia 12 de abril de 2022, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns Fabricio (PC) e Alex (PC), tendo as partes desistido do depoimento da testemunha André (PC), o que foi homologado. Em seguida, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado. A respeito do cálculo de pena, a pena-base poderá ser fixada acima do mínimo legal, em razão da diversidade e natureza das drogas localizadas com o réu, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343. Incidirá a agravante da reincidência. Na terceira fase, inviável o reconhecimento do art. 33, §4º da Lei n.º 11.343. O regime deverá ser o fechado. Em virtude da reincidência e da pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Pelo mesmo motivo, incabível o sursis. A prisão preventiva deverá ser mantida, dada a gravidade concreta da conduta do agente, que, inclusive, voltou a incidir em novo crime. Requeiro o perdimento do valor apreendido (fls. 139/140). A Defensoria Pública, preliminarmente, manifestou-se que no ato da abordagem ao autuado não estavam presentes os fundamentos legais para a realização de revista pessoal. Segundo os policiais, o que motivou a abordagem foi o fato de o local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas e de o réu ter corrido quando avistou a viatura de polícia. Ou seja, foram violados os artigos 240, §2º, e 244, ambos do CPP. Por essas razões, requereu a declaração da ilicitude das provas que fundamentaram a imputação (art. 5º, LVI, da CF). Por conseguinte, requereu a absolvição do denunciado em relação ao fato descrito na denúncia, por falta de prova válida a respeito da materialidade do delito (art. 386, II, do CPP). Em conformidade com o princípio da presunção de inocência e o célebre brocardo in dubio pro reo, requereu, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Caso mantida a condenação, postulou: a fixação da pena-base no mínimo legal; a quantidade de drogas apreendida não evidencial a especial reprovabilidade da conduta; a suposta maior nocividade da cocaína não justifica a exasperação da pena quando a quantidade total de drogas apreendidas não seja substancial; seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois os policiais afirmaram que o réu confessou os fatos; seja fixado o regime inicial semiaberto; seja concedido o direito de apelar em liberdade. Por fim, pleiteou a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, porque a acusada é pobre na acepção jurídica do termo e se encontra patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 138/142).

O laudo de exame químico-toxicológico - laudo definitivo foi acostados aos autos às fls. 151/153, tendo o Ministério Público reiterado as manifestações anteriores e a Defensoria Pública reiterado as alegações finais apresentadas (fl. 158 e fl. 159, respectivamente).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A preliminar arguida pela nobre defesa do acusado Wilson para declarar a ilicitude das provas por violação dos artigos 240, §2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, não comporta provimento.

No que se refere a busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. No presente caso, os policiais civis estavam participando da operação denominada "Divisas", operação visando coibir o tráfico de drogas e, para isso, realizaram

diligências no local dos fatos, local já conhecido pela mercancia de drogas. Ao chegarem no local, adentraram e o policial Alex visualizou um indivíduo que, ao perceber que se tratava de polícia, saiu correndo dispensando uma sacola plástica com drogas.

Assim, verifica-se a configuração das fundadas razões exigidas pela lei processual e, existindo fundada suspeita de que o indivíduo estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada, consoante já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. O alegado constrangimento ilegal é analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE.

1. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

2. Na espécie, ao contrário do que sustentado na impetração, o paciente não foi revistado simplesmente por ser do sexo masculino e estar no interior de um ônibus, mas sim porque, durante operação que objetivava combater roubos em coletivos, deixou para trás uma sacola que trazia consigo e dirigiu-se à porta do veículo, o que causou estranheza nos policiais que realizavam a abordagem, que pegaram o objeto para averiguação, oportunidade em que localizaram drogas em seu interior.

3. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. RÉU REINCENTE. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO DISPOSITIVO LEGAL EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. Não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 ao réu reincente, pois não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. Precedentes.

2. Estando-se diante de acusado condenado à pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos de reclusão, não há que se falar em fixação de regime mais brando para o resgate da reprimenda corporal, tampouco na sua substituição por sanções restritivas de direitos, já que não atendidos os requisitos objetivos previstos nos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal.

3. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus n.º 552.395 - SP (2019/0376238-6), Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 20/02/2020, Dje 05/03/2020) (Grifei);

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Hipótese em que o Tribunal de origem, diante das circunstâncias peculiares do caso - veículo parado em atitude suspeita, durante a madrugada, com quatro indivíduos em seu interior - entendeu haver fundada suspeita para a realização da abordagem pessoal, que resultou na apreensão de arma de fogo. A decisão vergastada está em consonância com o art. 244 do CPP e os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido são legítimos para fins de busca pessoal. Rever a conclusão do aresto necessitaria do reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 1.403.409/RS, Sexta Turma, Rel. Min.

Rogério Schietti Cruz, DJe de 04/04/2019) (Grifei).

Ademais, destaca-se que a presunção dos agentes públicos sobre a prática delituosa se revelou acertada, tanto é que na abordagem foram apreendidas 52 porções de maconha, com massa líquida de 195,12 gramas, e 55 porções de cocaína, com massa líquida de 22,25 gramas.

Nesse compasso, portanto, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância.

Superada a preliminar, no mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição/apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação provisório (fls. 13/17 repetido às fls. 133/137), fotografias (fls. 30/31), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 151/153), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA e TETRAHIDROCANNBINOL-THC, bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado WILSON CONCEICAO BOTELHO CABRAL JUNIOR, em solo policial, usou seu direito de permanecer em silêncio e manifestar-se apenas em juízo (fl. 09). Em juízo, disse que é amasiado. Tem dois filhos: um de três meses e outro com cinco meses. Estudou até o 1º colegial. Quando foi preso trabalhava como vidraceiro, sem registro em carteira. Já respondeu a processo por roubo. Já tinha cumprido a pena quando foi preso. Negou os fatos narrados na denúncia. Disse que tinha ido comprar maconha, quando chegaram dois rapazes. Deu o dinheiro para um dos rapazes. Ao perceberem a chegada da viatura policial, o rapaz correu do local. Os policiais o mandaram sentar sobre as mãos. Ainda não tinham se apresentado como policiais. Disse para os policiais que não ia sentar sobre as mãos, pois não estava vendendo, mas comprando drogas. Só sentou sobre as mãos depois que os policiais se apresentaram como tais. Um policial de pele morena, que não viu na audiência, bateu seu rosto contra a parede e pisou com o coturno em seu pé. Esse policial perguntou se ele tinha passagem ao que respondeu que sim, um processo de 2011. Então esse policial falou para o outro: "achamos o culpado. Você avisou ao traficante? Agora você vai ficar no lugar dele.". Resistiu à prisão porque não estava vendendo drogas. O terceiro policial trazia uma mochila de entrega de pizza, também não viu esse policial na audiência. Esse policial retirou dessa mochila uma sacola contendo drogas e disse que era dele. Não sabe de onde saiu esse policial com a mochila de entrega de pizza. A polícia chegou no momento em que acabara de pedir a droga pelo muro. O rapaz chegou a pegar o dinheiro, mas viu a viatura e correu. O rapaz estava do lado de dentro do prédio. Disse que a versão dos policiais de que fica alguém do lado de dentro do prédio vendendo drogas e o usuário a adquire pelo muro é verdadeira. A venda é feita por cima do muro; não existe buraco no muro. O muro não é alto como dito pelos policiais. Não deu tempo de pegar a droga, pois a polícia chegou no exato momento em que o traficante pegou o dinheiro. De onde o traficante estava, conseguiu ver a viatura virando a esquina. O traficante correu rumo ao fundo do estacionamento. Não viu o que o traficante fez com as drogas, mas o muro tem 2 m de altura. Não havia ninguém na rua. Primeiro foi abordado por dois policiais; nenhum dos que prestou depoimento nesta audiência. Com ele não havia drogas; apenas 34 reais em dinheiro. O terceiro policial foi aquele que o agrediu e o quarto policial chegou com uma mochila de entrega de pizza contendo drogas. Não sabe se o policial veio por dentro do terreno. Não conhece o traficante de quem estava comprando drogas. Há vizinhos no local que viram quando foi preso, mas não sabe informar nomes. Mora três ruas abaixo do local em que foi preso. Não conhecia os policiais, mas acredita que o acusaram porque acreditaram que ele tivesse avisado ao traficante da chegada da viatura. Fica apenas uma pessoa no muro vendendo; quando ao olheiro mencionado pelos policiais este fica no final do estacionamento. Os dois rapazes que se aproximaram dele enquanto comprava maconha que mencionou no início do interrogatório são os que se apresentaram como policiais posteriormente. Eles se aproximaram a pé, como se fossem usuários. A seguir passou a viatura com o terceiro policial.

A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a

realidade probatória.

Os policiais civis FABRÍCIO PARISE BRANCO, ANDRÉ GIRALDELLI e ALEX SANDO PEREIRA DA SILVA, em sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que estavam participando da operação denominada "Divisas" operação esta que tem como escopo coibir o tráfico de drogas, juntamente com seus demais colegas de equipes. Realizaram diligência no local dos fatos, local este já conhecido pela mercancia de drogas. Ao chegarem no local desembarcaram da viatura os policiais Alex e Fabrício. Fabrício seguiu a pé pela rua e o policial Alex adentrou ao terreno baldio a frente, onde de saída visualizou um indivíduo, indivíduo este que ao perceber que se tratava de polícia, saiu correndo dispensando uma sacola plástica com drogas, o indivíduo correu e mais a frente pulou um muro onde foi detido pelo policial Fabrício. Na sacola dispensada pelo indivíduo identificado como sendo Wilson, havia 52 (cinquenta e dois) invólucros plásticos contendo maconha e 55 (cinquenta e cinco) invólucros contendo cocaína, também foram localizados um celular e R\$ 33,00 (trinta e três reais). Em ato contínuo conduziram o indivíduo e as drogas até a unidade policial, onde deram ciência a Autoridade policial (fl. 06, fl. 07 e fl. 08).

Em juízo, o policial civil FABRÍCIO PARISE BRANCO recorda-se do acusado de uma ocorrência de tráfico de drogas. No dia dos fatos, o depoente participava da operação denominada Divisa, que visava ao combate ao tráfico de drogas na região da delegacia. Deslocaram-se até um local já conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Como já haviam feito abordagens no local, já conheciam o modus operandi dos traficantes. A venda do entorpecente era feito em um terreno baldio e a droga era servida por cima do muro. O muro é alto, com cerca de 3 m de altura, justamente para dificultar a abordagem da polícia. Como já conheciam o modus operandi, Alex desembarcou da viatura e seguiu pela rua de baixo, que dá acesso ao terreno baldio e o depoente seguiu pela rua onde normalmente transitam os usuários. Previa-se que ao ver Alex no terreno, o indivíduo que estivesse vendendo drogas pularia o muro e seria detido pelo depoente. Ao ver a aproximação de Alex, o acusado pulou o muro e, como é alto, acabou caindo. O depoente tentou segurá-lo e ele começou a se debater. Algemou o acusado, que continuou se debatendo. Alex encontrou a droga dispensada do outro lado do muro e veio até onde estava o depoente em poder do acusado. O acusado foi a única pessoa vista dentro do terreno. Com o acusado foi encontrada a quantia de R\$ 33,00. Alex disse que encontrou a sacola no canto do muro por dentro do terreno. Quem viu a dispensa da droga pelo acusado foi Alex. O depoente não tinha visão por causa da existência do muro na frente. Como o terreno do lado de dentro do muro é alto, via-se o acusado sentado na ponta do muro. Dali era possível ele acompanhar a chegada de usuários. Esclareceu que o muro é alto para quem está na rua, contudo para quem está do lado de dentro, é possível ficar de pé debruçado sobre ele, como era o caso do acusado. Não chegou a presenciar ato de comércio. Na sacola dispensada pelo acusado havia aproximadamente 50 invólucros de maconha e 50 de cocaína. O réu confessou que estava traficando e que o dinheiro encontrado com ele era proveniente da venda. O policial André ficou acompanhando a ação de dentro da viatura. Não conhecia o acusado. Indagado sobre como concluiu que o acusado estava vendendo entorpecentes, respondeu que como já realizou prisões no local, sabe que aquele é o modo como se comporta o traficante: fica debruçado sobre o muro observando a chegada de potenciais usuários. Além disso, quando o acusado avistou o policial Alex, pulou o muro, o que provavelmente não teria feito se não estivesse traficando. Não havia outras pessoas dentro do terreno. Não havia ninguém na rua, nenhum olheiro.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil ALEX SANDO PEREIRA DA SILVA, o qual, em juízo, recorda-se do acusado de uma ocorrência de tráfico de entorpecentes. Na data dos fatos participavam da operação Divisa com vistas ao combate do tráfico de entorpecentes. A equipe A, composta pelo depoente, André e Fabrício se dirigiu ao local do fato, já conhecido como ponto de traficância. Chegando ao local, o depoente e Fabrício desembarcaram e seguiram a pé: Fabrício subiu por uma rua e o depoente seguiu por um terreno baldio que dava acesso ao estacionamento de um condomínio. É nesse estacionamento que ocorre o tráfico de entorpecentes. O policial André permaneceu na viatura onde tinha o visual do

policial Fabrício. O acusado, ao perceber sua aproximação, empreendeu fuga e abandonou uma sacola com entorpecentes. O acusado pulou o muro e, do outro lado, foi abordado por Fabrício. Viu quando o acusado dispensou a sacola; ele se encontrava numa espécie de corredor entre garagens. O depoente pegou a sacola com as drogas e foi até onde estava Fabrício tentando deter o acusado. A seguir o policial André chegou e os ajudou a conter o acusado. Na sacola havia maconha e cocaína, aproximadamente 50 invólucros de cada. Na posse do acusado havia uns trinta e poucos reais. Confessou informalmente que estava traficando. Indagado sobre quem lhe fornecia as drogas, disse que não conhecia a pessoa. Já era de seu conhecimento que o tráfico se faz no interior do estacionamento e que com a aproximação de viaturas, os traficantes pulam o muro, que mede aproximadamente 3 m de altura. Há também a presença de um olheiro. A droga é servida por meio de um buraco existente no muro. Não percebeu a presença de ninguém, além do acusado, pois não veio pela rua e sim por um terreno baldio pelo qual conseguiu acesso ao estacionamento do condomínio. Não viu olheiro ou outras pessoas no local no momento.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

“Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, diante dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais ouvidos tanto na fase policial quanto em juízo, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que WILSON trazia consigo, para fins de tráfico, os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Em que pese o acusado Wilson ter negado o envolvimento com as drogas apreendidas, dizendo que estava no local apenas para comprar entorpecente, fato é que a nobre

defesa não se incumbiu de provar tal negativa.

A versão apresentada pelo acusado foi completamente rechaçada pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da operação. Os policiais Fabricio e Alex foram enfáticos ao afirmarem que o local é conhecido como ponto de tráfico e no momento da abordagem Wilson estava sozinho no local, sem contar que o policial Alex visualizou o acusado abandonando/dispensando uma sacola com entorpecentes, além de ter sido localizado em seu poder a quantia de R\$ 33,00.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Assim, se a condenação se baseia nos depoimentos seguros e uníssonos de dois policiais civis, a Defesa se baseia na singela negativa do réu, desguarnecida de qualquer prova, o que é insuficiente para afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com os entorpecentes apreendidos, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas (52 porções de maconha, com massa líquida de 195,12 gramas, e 55 porções de cocaína, com massa líquida de 22,25 gramas), incompatíveis com a posse para uso, da forma como estavam embaladas, separadas, bem como das circunstâncias que envolveram a abordagem e prisão do denunciado, com apreensão de dinheiro e tentativa de fuga.

Vale ressaltar que o fato do réu não estar vendendo entorpecentes no momento da abordagem policial, não desconfigura o delito de tráfico de drogas, eis que o tipo penal é de ação múltipla, configurando o crime aquele que pratica qualquer uma das condutas ali descritas, entre as quais a de trazer consigo o entorpecente destinado ao fornecimento a terceiro, conduta esta imputada ao acusado cuja prova restou incontroversa.

Sobre o assunto abarca a jurisprudência:

“É certo que a comprovação exigida pelos delitos previstos nos artigos 33, “caput” e 28, da Lei de Drogas, não é de fácil constatação, sendo certo que, tal análise deve ter por base as provas extraídas da própria situação fática. Desse modo, para que não se cometam injustiças confundindo usuários com traficantes, para configuração das condutas criminosas previstas na Lei em comento, deverão ser analisadas a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do acusado. Também deve se levar em consideração a forma de acondicionamento da droga”. (Apelação nº 0054000-21.2008.8.26.0114, Rel. Des. Borges Pereira, 16ª Câmara. Direito Criminal).

Em outras palavras, traficante “não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas” (RF 320/237).

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito

se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo" (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: "considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente." (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

É importante salientar que a condição de usuário de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o usuário ingressa no comércio espúrio para sustentar seu uso.

A relevante quantidade de droga apreendida, somada às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, não parecendo crível que o acusado trazia consigo tal quantidade de droga para consumo próprio.

Afasta-se, portanto, o pleito absolutório formulado pela nobre defesa, e pelos mesmos fundamentos, o pedido de desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu cometeu o delito nas condições normais previstas no tipo penal, razão pela fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Observo que a quantidade de entorpecente apreendida não se mostra excessiva a justificar o aumento da pena-base (52 porções de maconha, com massa líquida de 195,12 gramas, e 55 porções de cocaína, com massa líquida de 22,25 gramas).

Na segunda fase da pena, ausentes circunstâncias atenuantes a serem observadas. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de roubo (processo n.º 0046670-29.2012.8.26.0050 da 4ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, conforme

certidão estadual de distribuições criminais de fls. 126/127 e F.A. de fls. 121/125) sendo, portanto, reincidente. Assim, acresço suas penas de 1/6 (um sexto), fixando-as em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Observo que o acusado judicialmente alegou apenas que estava no local para comprar maconha, negando, portanto, a traficância, o que impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme requerido pela nobre defesa. Aliás, de acordo com o teor da Súmula n.º 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual torno as penas definitivas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Observo que, em face da reincidência, fica afastada a causa de diminuição de pena tipificada no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06. Não há que se falar em bis in idem mormente porque, para incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o réu seja primário, o que não se verifica no caso em análise. Esse é o forte posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE DOIS DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTA QUE EXTRAPOLOU À INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA E TERCEIRA FASES QUE NÃO ENSEJA BIS IN IDEM. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO MONTANTE DA REPRIMENDA IMPOSTA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - A reincidência do paciente constitui óbice suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista não estar preenchido o requisito legal da primariedade. Precedentes. - Ademais, a orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...)" (AgRg no HC 630.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (Grifei);

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. In casu, tratando-se de réu reincidente (condenado anteriormente por roubo), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1509254/AC, STJ, Rel.

Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)
(Grifei);

“(...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...) 8. Habeas corpus não conhecido”. (STJ HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.03.2018, DJe 20.03.2018 g.n.).

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288). Diante da quantidade da pena imposta e reincidência do agente incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em se tratando de delito equiparado a hediondo, o regime inicial para o cumprimento de pena é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostraram adequados para a ressocialização do réu, além do fato do réu ser reincidente, evidenciando que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito. Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito as seguintes jurisprudências:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto por lei, o fato do acusado ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá o réu recorrer liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº. 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante das condições subjetivas e a quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz

à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR WILSON CONCEICAO BOTELHO CABRAL JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Considerando-se a relação do dinheiro apreendido (R\$ 33,00 - auto de exibição e apreensão de fls. 18/19) com o tráfico ilícito de entorpecente, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Antidrogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 07 de julho de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA